Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Processo: 0804991-80.2017.8.12.0001
Autos: Procedimento Comum Cível
Autor: Fernando Teruo Higa da Silva
Réu: Unimed Campo Grande-MS

Vistos, etc.

Trata-se de *Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais* ajuizada por **Fernando Teruo Higa da Silva (menor representado por sua mãe Lúcia Higa**) em face de **Unimed Campo Grande – Cooperativa de Trabalho Médico,** qualificados nos autos, alegando, em síntese, que o autor necessita de tratamento pelo método ABA em clínica especializada, por ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo (CID F84.0), e que a requerida negou a cobertura do tratamento, sob a justificativa de que ele não está no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS.

Requer, assim:

- inversão do ônus da prova;
- benesses da justiça gratuita;
- concessão de tutela de urgência, determinando que a ré custeie o tratamento do autor (reabilitação em psicologia – método ABA, terapia ocupacional com espcialidade em integração sensorial), por tempo indeterminado, diariamente, envolvendo psicologos, fonoaudiólogos e especialistas que tratem a CID F84.0;
- procedência do pedido, ratificando-se a tutela de urgência;
- indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Às f. 102/105,foi deferido o benefício da justiça gratuita em favor do autor, foi invertido o ônus da prova, porém foi indeferido o pleito antecipatório autoral ante a ausência de especificação quanto à periodicidade, duração e valor do tratamento pleiteado pela parte autora. Ao final, designou-se audiência de conciliação.

A requerente se manifestou às f. 117/119 e juntou os documentos de f. 120/130, pugnando pela reapreciação do seu pleito antecipatório.

Às f. 131/136, foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida custeie ao autor, pelo prazo de 1 ano, o tratamento ABA (a ser realizado cinco vezes na semana, em sessões com duração de uma hora cada, na Clínica Espasso Programa Comportamental) e o tratamento de Terapia Ocupacional (a ser realizado três vezes por semana, em sessões com duração de uma hora e meia cada, a serem realizadas pelas profissionais Érica Sinzato Grabalos CREFITO 12/6435/TO e Camila Balbuena G. De Almeida CREFITO 13-6719/TO). Para tanto, determinou-se que a requerida fizesse, em quarenta e oito horas, o pagamento de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) à Clínica Espasso, referente à mensalidade do tratamento ABA, bem como, realizasse a quitação dos valores atinentes à primeira mensalidade do tratamento de terapia ocupacional, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por sessão, junto às profissionais Érica Sinzato Grabalos CREFITO 12/6435/TO e Camila Balbuena G. De Almeida CREFITO 13-6719/TO), assegurando a realização de tais procedimentos pelo autor, sob pena de multa diária.

A audiência de conciliação realizou-se à f. 142, em que as partes não se compuseram.

A parte requerida manifestou-se às f. 143/144, afirmando que as

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

sessões de terapia ocupacional devem durar quarenta minutos, segundo indicação da terapeuta Camilla Balbuena Garcia de Almeida, e não uma hora e meia, conforme foi deferido em tutela antecipada. Por tais razões, requereu a adequação da decisão de f. 131/136, para que se determine que a terapia ocupacional seja realizada em sessões de quarenta minutos. O autor, à f. 193, concordou com o pedido de adequação da tutela.

Às f. 194/195 foi deferido o pedido de adequação da tutela antecipada formulado pela ré às f. 143/144, para constar que a duração da sessão de terapia ocupacional tem duração de quarenta minutos.

A requerida apresentou contestação às f. 198/222, na qual alegou, em síntese, que o autor poderia ter contratado o denominado "plano referência", que possui cobertura ao tratamento pelo método ABA, todavia optou por contratar o plano que abrange apenas as coberturas mínimas da ANS. Afirmou que o tratamento pelo método ABA trata-se de um serviço eletivo, que não está englobado pelo contrato firmado entre as partes, tampouco encontra guarida no rol de eventos e procedimentos mínimos e obrigatórios, além de decorrente de escolha voluntária do serviço perseguido e não gozando de caráter iminente, de modo que inexiste a obrigação da requerida e custeio. Aduziu que o tratamento com ABA não implica em cobertura do "aplicador", que deve sempre ser um familiar, não sendo possível transferir tal responsabilidade a terceiros às custas da ré. Sustentou que a terapia ocupacional e fonoaudiologia podem ser realizadas por profissionais credenciados sem custo adicional e que a cobertura deverá estar limitada ao acompanhamento psicológico, com treinamento e orientação dos familiares para a aplicação do método ABA, excluindo do dever da requerida a obrigatoriedade de custear o aplicador/cuidador. Defendeu que não descumpriu qualquer obrigação de ordem legal ou contratual, não cabendo falar em indenização por danos morais. Ao final, pediu a improcedência dos pedidos iniciais. Em assim não se entendendo, requereu subsidiariamente que o deferimento fique restrito ao acompanhamento psicológico, excluindo expressamente a obrigatoriedade em custear o "aplicador". Caso se entenda pelo deferimento de todo o tratamento, que fique estipulado que ocorra em rede credenciada da operadora ou, em assim não se entendendo, que a obrigação da ré fique limitada ao valor de tabela. Pugnou pela improcedência do pedido de indenização.

Réplica às f. 381/395, em que o autor impugnou os argumentos apresentados na contestação e juntou documentos às f. 396/404.

A requerida manifestou-se acerca da documentação às f. 416/419.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, a ré pugnou pela produção de prova pericial, documental, testemunhal e depoimento pessoal na pessoa da sua representante legal (f. 416/419) e o autor requereu a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais das partes e oitiva de testemunhas (f. 443/445). O Ministério Público requereu a realização de perícia médica, juntada de documentos e não se opôs à produção de prova oral, pugnando pela designação de audiência (f. 449/451).

O autor manifestou-se às f. 476/478, requerendo a concessão de nova tutela de urgência, diante do término da vigência da decisão, anexando documentos às f. 479/485.

Às f. 487/492, diante da necessidade de continuidade no tratamento do autor, autorizou-se a manutenção da tutela de urgência, mesmo após decorrido o prazo de 1 ano. Foram fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova documental. Autorizou-se a realização de perícia, cujos honorários devem ser antecipados pela ré. Quanto ao pedido de prova oral, postergou-se sua análise.

A ré, às f. 495/497, comunicou que, atualmente, credenciou clínica que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

realiza o tratamento exigido pelo requerente, razão pela qual pediu autorização para que a tutela de urgência fosse cumprida por seus profissionais credenciados. A autora, por sua vez, impugnou o pleito (f. 526/531).

Proposta de honorários periciais à f. 512 (R$ 4.770,00), a qual foi paga pela ré (f. 542).

Às f. 547/549, postergou-se a análise do pedido de f. 495/497 e, para se apurar se era possível a mudança de profissional no tratamento do autor, inclui-se novos quesitos para análise do perito.

Laudo pericial às f. 574/583, tendo as partes se manifestado às f. 586/589 e 597.

Esclarecimentos do expert às f. 604/608, tendo as partes se manifestado às f. 611/612 e 620/621. O Ministério Público também tomou ciência do laudo e manifestou-se às f. 625/633.

À f. 634, homologou-se o laudo pericial e designou-se audiência de instrução e julgamento.

A ré desistiu do depoimento pessoal da representante legal do autor (f. 650), o que foi homologado à f. 654.

Termo de assentada à f. 696, no qual constou que as partes não se compuseram. O autor desistiu do depoimento pessoal da ré e a requerida desistiu das testemunhas Lúcia Higa, Ana Cecília Cançado Soares Costa, Ana Cristina Lima Espindola Geraldi e Erica Eiko Tome Sinzato Grabalos, o que foi homologado pelo juízo. Ouviu-se a informante Eliana Araujo e Silva Félix. Ao final, concedeu-se prazo para alegações finais.

Alegações finais da ré às f. 700/705 e do autor às f. 723/729.

Parecer Ministerial às f. 736/742, no qual opina pela procedência do pedido.

Relatados. Decido.

Trata-se de *Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais* ajuizada por **Fernando Teruo Higa da Silva (menor representado por sua mãe Lúcia Higa**) em face de **Unimed Campo Grande – Cooperativa de Trabalho Médico,** qualificados nos autos**.**

1 – Da Obrigação de Fazer

Como é sabido, a atividade de prestação de assistência médico-hospitalar está abrangida pelo Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, parágrafo 2º:

> *"Art. 3. (...)*
> *§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista."*

Se assim o é, os contratos envolvendo relação de consumo têm de ser interpretados à luz do novo paradigma protetivo e de princípios tais como: "vulnerabilidade do consumidor" (art. 4ª, I, do CDC); "da interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

favorável ao consumidor" (art. 47, do CDC), entre outros, competindo ao julgador, no caso concreto, ponderar os fatos apresentados, de sorte a tomar a decisão que mais se aproxima do justo. Demais disso, em caso de conflito entre o interesse do usuário e o interesse do fornecedor, o contrato deverá ser interpretado favoravelmente ao consumidor (pró-consumidor) segundo a disposição constante do artigo 47.

De razoável compreensão que ao contratar os denominados planos de saúde, busca-se mais que simples consultas e exames laboratoriais, mas também, a garantia de assistência médica de qualidade, abrangendo todo o tratamento e recuperação da enfermidade, admitindo-se, no máximo, distinções quanto ao conforto das acomodações hospitalares oferecidas aos contratantes, variável da simples enfermaria às suítes de luxo, que alguns conseguem pagar.

No caso dos autos, a controvérsia reside na negativa da parte requerida em fornecer o tratamento recomendado por médico credenciado da referida instituição, consistente na aplicação do método ABA ao menor Fernando Teruo Higa da Silva, **portador de transtorno do espectro do autismo (CID 10 – F84), conforme atestado médico de f. 100, (assinado pela médica pediatra Dra. Emília E. T. Alves, na data de 03/03/2017) e de f. 101 (assinado pela médica especialista em neurologia infantil, Dra Maria Eulina Quiião, na data de 09/03/2017):**

Espaço A

A UNIMED -

Solicito p/ menor Fernando Teruo Higa da Silva, portador de TEA, necessidade pelo método ABA e acompanhamento c/ T.O.

Emília E. T. Alves
Pediatra e Neuropediatra
R.Q.E. 1784/2202
CRM-MS 1306

03/03/17

Campo Grande/MS, 9/3/2017

laudo

Menor Fernando Teruo Higa da Silva, 4anos, com Transtorno do espectro Autista e microcefalia.
TC e BERA: normal.
PC<2,5%.
Solicito professor auxiliar e cuidador no recreio.
Solicito **ABA**, diário, por tempo indeterminado, de acordo com avanços do menor, sendo uma estimulação adequada e indicada, a nível mundial, para portadores de TEA, com grandes avanços no quadro e melhora do prognostico.
CID: **F84**/G80

Dra. Maria Eulina Quiião
Neurologia Infantil
Especialista em Desenvolvimento
CRMMS 3276

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

Anote-se, ainda, que o laudo de f. 123/124 (assinado por fonoaudiólogo – Dra. Ana Cecília Cançado), o laudo de f. 125/130 (assinado por terapeuta ocupacional Dra Erica Sinzato) e o proprio laudo pericial de f. 574/583, corroboram o diagnostico do requerente (transtorno do espectro autista) e a necessidade do tratamento pelo método ABBA:

1. Quais as alterações de saúde do menor Fernando Teruo Higa da Silva com CID 10.

O paciente Fernando, pelos relatos dos autos, apresenta um quadro de TEA (Transtorno do Espectro Autista), com deficiências na comunicação e interação social, além de alterações no comportamento e na motricidade, com um quadro de microcefalia associado.

CID: F84.0

6. O diagnóstico de autismo foi firmado em que data?

O diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) foi feito aos 3 anos

15. Quais as formas de tratamento para o paciente autista?

O tratamento para o TEA envolve uma equipe multidisciplinar, acompanhamento com fonoaudióloga, pelo atraso da linguagem e déficits na comunicação verbal e não verbal, acompanhamento com Terapeuta Ocupacional especialista em integração sensorial, pelas alterações sensoriais que o paciente com TEA apresenta e intervenções comportamentais com métodos específicos, como o método ABA, que é realizado diariamente, além do acompanhamento com Neurologista Infantil que avaliará o desenvolvimento e indicará as terapias e o tratamento medicamentoso necessário, conforme os sintomas apresentados pelo paciente.

16. O método Applied Behavior Analysis – ABA é o único tipo de terapia que pode ser usada para estímulo do autista?

O método ABA não é a única Terapia, mas é a principal estratégia, com base em evidências cientificas, no trabalho com crianças do espectro autista, sendo que muitos estudos comprovam a sua eficácia, principalmente na intervenção precoce e intensiva de crianças com TEA até os 5 anos de idade, associado a Fonoaudióloga e Terapia Ocupacional especializada em integração sensorial. Outros métodos de intervenção que se destacam: TEACH, Son-Rise e Floortime.

17. O método ABA é exclusivamente de caráter médico?

O método ABA é indicado por um médico, mas é executado por uma equipe de terapeutas, como psicólogos, fonoaudiólogos e técnicas que tiveram treinamento para aplicação do método.

21. Considerando que a criança necessita de tempo lúdico, quais seriam as terapias e qual a freqüência, para não sobrecarregar a agenda do menor?

A intervenção deveria ser realizada com método ABA, 1 hora diariamente, acompanhamento com Terapia Ocupacional especializada em integração sensorial, duas vezes na semana, além da fonoaudióloga 2 vezes na semana, por período indeterminado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

A parte ré, por sua vez, negou o tratamento ao requente, ao argumento de que o procedimento pleiteado não encontra-se coberto pelo plano ou previsto no rol de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, conforme documento de f. 84/85:

Informamos que a solicitação do pedido eletivo de nº. 00110378, contendo o procedimento abaixo listado, não foi autorizada com base na seguinte justificativa:

Descrição do Procedimento:	Código TUSS:	Quantidade:
Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada)	----------	01
Observação:		

JUSTIFICATIVA CONTRATUAL:

Procedimento não é coberto pelo rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS (RN nº 387/2016 da ANS).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Servimo-nos do presente para esclarecer que a solicitação, visando à autorização para o procedimento supracitado, fora negada, considerando que o contrato aderido por V.S.ª, está vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (lista de procedimentos) da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, onde tal solicitação não se enquadra atualmente disposta na Resolução Normativa (RN) nº 387/2015, conforme se verifica na **Cláusula Décima Primeira - Exclusões de Cobertura, item 10.1**, transcrita abaixo:

Pois bem. Sabe-se que na atualidade, já não é aceitável alegar-se o pacta sunt servanda para legitimar cláusulas contratuais abusivas, porquanto a relação jurídica que lhes deu origem é regulada pelo Código de Proteção e de Defesa do Consumidor e, frente a tais disposições, as chamadas cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, cujo reconhecimento poderá ocorrer a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; muito mais se inseridas nos chamados contratos de adesão.

Tal fato nos leva à conclusão de que, ao contrário do que defende a empresa ré, o fato de inexistir previsão de cobertura para o tratamento em questão no rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, por si só, não torna legítima a recusa, **haja vista que o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo**, sendo mera referência para cobertura assistencial dos planos de saúde, pois busca delimitar os procedimentos mínimos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde, não significando exclusão dos demais.

Não se presta, pois, para excluir direitos do consumidor, mas apenas para hierarquizar certos procedimentos como essenciais, de modo que não sejam passíveis de exclusão.

O Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/1998 não proíbem o estabelecimento de restrições aos direitos dos consumidores. No entanto, a permissão em tela não é absoluta. É limitada pela própria lei e pelos princípios que regem as relações de consumo, sendo certo que o artigo 51 do CDC estabelece serem abusivas, dentre outras, as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (inciso IV).

O § 1º do citado artigo, por sua vez, registra ser presumidamente exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual (inciso II).

Igualmente, em se tratando de relação de consumo, é importante mencionar o teor do art. 6º, V, do CDC, qual seja, é direito básico do consumidor "*a*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas".

A aplicação das referidas disposições legais ao caso em análise evidencia a abusividade da negativa de cobertura quanto ao procedimento necessitado pela parte autora pelo simples fato de não constar em rol da ANS.

O contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado pelas partes dos autos em epígrafe exclui, em sua cláusula 10.1, "*Em conformidade com o que prevê a Lei n. 9656/98 estão excluídos de cobertura do plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (...)*" – f. 47. **Ocorre que é certo que o contrato pode dispor sobre as patologias cobertas e não sobre o tipo de tratamento. O médico não pode ser impedido de escolher o tratamento mais adequado, uma vez que pretende a preservação da vida do paciente, bem como a melhora na qualidade da existência, com fundamento, inclusive, no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).**

Oportuno mencionar que o art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estatui que o plano de assistência à saúde abrange tratamento para as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças - CID (dentre as quais está o Transtorno Global de Desenvolvimento – Espectro Autista – CID 10 F84.0), excluindo algumas hipóteses de cobertura dos planos de saúde, não havendo menção ao tratamento por terapia comportamental (método ABA), prescrito ao requerente, consoante laudos médicos de f. 100/101, f. 123/124, 125/130 e o proprio laudo pericial de f. 574/583.

Assim, não há como a requerida se valer da Resolução da ANS para afastar o fornecimento do tratamento pleiteado pelo autor, ainda mais quando foi requisitado por médicos que acompanham o caso desde o início do tratamento.

O E. TJMS já se manifestou sobre a questão, confira-se:

> *APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COBERTURA DE TRATAMENTO ESPECÍFICO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (ABA) - AUTISMO - PERÍODO DE CARÊNCIA DISPENSADO QUANDO DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE CUMPRIR COM A OFERTA PROMETIDA NA VENDA - ROL DA ANS - EXEMPLIFICATIVO - NEGATIVA DE COBERTURA - ABUSIVA - DANOS MORAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.* ***O autor/apelado é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F 84.0) e necessita de terapia pelo método ABA, com acompanhamento conjunto de psicólogo, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia, conforme laudos e documentos acostados aos autos.*** *A oferta de dispensa de carência e cobertura de reembolso dos valores das terapias necessárias ao segurado, nas tratativas de venda do plano de saúde, vincula o fornecedor dos serviços, nos termos do art. 30 do CDC* ***Com efeito, os contratos de assistência à saúde firmados entre particulares têm natureza aleatória e relevante finalidade social, não podendo prevalecer a tese de que a***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

> ***cobertura de procedimentos esteja restrita aos casos previstos no instrumento contratual ou no rol publicado pela ANS, sob pena de desequilíbrio da avença em desfavor do consumidor aderente, que ficaria, assim, privado de usufruir de qualquer procedimento decorrente do avanço na medicina****. No caso vertente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, é razoável, revelando-se adequado e suficiente tanto para cumprir a função compensatória da indenização à vítima, como para atingir o escopo pedagógico direcionado ao ofensor, considerando o bem jurídico ofendido (direito à saúde), assim também o suporte financeiro da condenada. (TJMS. Apelação Cível n. 0803487-31.2020.8.12.0002, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 13/05/2022, p: 17/05/2022).*

Não fosse isso, compete aos profissionais médicos à análise da adequação dos procedimentos a serem utilizados para o tratamento de uma patologia, não sendo razoável que a cooperativa se imiscuir na escolha do tratamento a ser utilizado para o acompanhamento da doença que acomete seu associado, limitando-se a dizer que o mesmo é eletivo.

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA E DE INTERVENÇÃO COM PROFISSIONAIS QUE POSSUAM ESPECIALIDADE (REABILITAÇÃO COM MÉTODO ABA, FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO – DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA – PRECEDENTES DO STJ – COBERTURA DEVIDA SEM LIMITAÇÕES – OPTANDO A PARTE AUTORA EM REALIZAR O TRATAMENTO EM CLINICA DE LIVRE ESCOLHA, OS GASTOS COM FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DEVERÃO SER REEMBOLSADOS DE ACORDO COM OS LIMITES DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (**TJMS**. Apelação Cível n. 0838079-12.2017.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 10/05/2022, p: 11/05/2022).*

No caso vertente, realizou-se prova pericial a fim de analisar a real necessidade do tratamento requisitado pelos médicos do requerente, sendo o perito nomeado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

judicialmente enfático ao concluir que (f. 583):

> **Em conclusão, o quadro neurológico apresentado é indicativo de Terapia Ocupacional através do Método ABA, reabilitação que deve ser feita com profissional comprovadamente especialista em Integração Sensorial e Método ABA.**

Portanto, não há que se discutir a necessidade ou não, mas a conveniência da utilização desses métodos, vez que, nas palavras do perito judicial, "***(...) O paciente tem indicação de realizar a intervenção com método ABA (analise do comportamento aplicado), uma vez que o método atua em várias questões do desenvolvimento.*** *No caso do paciente será importante para o ensinamento de novas habilidades funcionais, além de habilidades de comunicação e habilidades sociais, além de manter comportamento, como o ensino de procedimentos de autocontrole, além de reduzir comportamentos de interferência. (...) A patologia se enquadra nos casos de urgência, uma vez que a intervenção precoce até os 5 anos, preferencialmente até os 3 anos de idade, modifica a evolução doença.* ***Dessa forma, a não realização da intervenção multidisciplinar e com métodos específicos implicará em atrasos irreparáveis no desenvolvimento e na vida do paciente***" (f. 582), inexistindo, portanto, dúvidas de que é dever da ré, na qualidade de plano de saúde, arcar com o tratamento médico prescrito ao seu beneficiário.

Ademais, não há que se falar em aplicação do recente entendimento esposado pelo E. STJ (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP), vez que aquele julgado não se deu no rito de recurso repetitivo e, portanto, não vincula este juízo.

Assim, verificando-se que o tratamento comportamental através do método ABA era indicado ao autor, conclui-se, portanto, ilícita a recusa da requerida Unimed em não fornecer o tratamento através dos procedimentos requisitados por médico especialista para melhora nas condições de vida do requerente, impondo-se a procedência do pedido, para o fim de obrigar a ré a fornecer o tratamento dispensado à doença do autor, mediante método ABA, durante o período necessário e expressamente recomendado pelo profissional médico que a assiste ao infante.

Há de se anotar que o tratamento a ser custeado pela ré (método ABA) deverá ser feito por profissionais especialistas em integração sensorial, conforme anotado pelo expert à f. 576, sob pena de prejuízos ao desenvolvimento do menor, com "*estagnação do desenvolvimento das habilidades motoras e sensoriais*" (f. 576).

Assim, tendo em vista que a ré não demonstrou nos autos que possui profissionais especializados nesta área, já que o documento de f. 498 apenas aponta a prestação de serviços de terapia ocupacional, mas sem mencionar a especialidade em integração sensorial (ônus que lhe competia), julgo procedente o pedido e **determino que a ré custeie ao autor, Fernando Teruo Higa da Silva, o tratamento ABA (a ser realizado 5 (cinco) vezes na semana, em sessões com duração de uma hora cada, na Clínica Espasso Programa Comportamental) e do tratamento de Terapia Ocupacional (a ser realizado 3 (três) vezes por semana, em sessões com duração de 40 minutos cada, a serem realizadas pelas profissionais Érica Sinzato Grabalos CREFITO 12/6435/TO e Camila Balbuena G. De Almeida CREFITO 13-6719/TO), durante o período em que for necessário para a conclusão do tratamento**, conforme laudo médico de f. 123/124 e 125/130, restando

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

ratificada a tutela de urgência deferida nos autos.

2 – Dos Danos Morais

Demonstrada a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento multidisciplinar pelo método de análise do comportamento aplicado (ABA), é importante analisar se a recusa da Unimed em autorizar o tratamento em tela constitui um ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Conforme anteriormente consignado e demonstrado, a relação jurídica existente entre as partes é regida pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento, prevista no artigo 14 do CDC:

> *"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.*
> *§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:*
> *I - o modo de seu fornecimento;*
> *II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;*
> *III - a época em que foi fornecido.*
> *§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.*
> *§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:*
> *I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;*
> *II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.*
> *§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."*

O Código de Defesa do Consumidor consagrou a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar.

Não obstante a Lei Consumerista prever a responsabilidade objetiva, não afastou a necessidade de demonstração dos demais requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil (fato lesivo causado pelo agente, por ação ou omissão, ocorrência de um dano patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente) para que exista o dever de indenizar.

Logo, o direito à reparação do dano depende da concorrência dos três requisitos acima delineados.

Evidente que aquele que espera tratamento e vê seu pedido negado sofre angústias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Com efeito, na hipótese dos autos, ficaram suficientemente demonstrados o ato ilícito (recusa da cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

análise do comportamento aplicado (ABA), o dano moral suportado pelo requerente e o nexo de causalidade entre ambos. Nesses termos, conforme teor do art. 927 do CC, presente o dever de indenizar.

É incontroverso que houve recusa da cobertura de tratamento indispensável à melhora da qualidade de vida do requerente, sendo evidente que a doença que o acomete, qual seja, autismo, trata-se de enfermidade grave e que exige estímulos específicos para o melhor desenvolvimento.

Assim, a demora na autorização do tratamento, que somente foi obtida na via judicial, através de liminar, provocou angústia e aflição psicológica, gerando dano moral passível de indenização.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradamente sobre o tema:

> *"conquanto a jurisprudência do STJ seja no sentido de que o mero inadimplemento contratual não ocasiona danos morais, esse entendimento deve ser excepcionado nas hipóteses em que da própria descrição das circunstâncias que perfazem o ilícito material é possível se verificar consequências de cunho psicológico que são resultado direto do inadimplemento. - A recusa indevida à cobertura médica ocasiona danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado (...)" (RESP 107230//RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.05.2010).*
>
> *"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO. COBERTURA. NEGATIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 2. O valor fixado a título de indenização por dano moral, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, encontrando-se dentro dos parâmetros reconhecidos pelo STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 418.277/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).*
>
> *AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJUSTA A RECUSA DE COBERTURA POR PARTE DO Apelação Cível nº 1.239.351-2 fls. 14 PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada, ancorada em precedente da Segunda*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

Seção, adotou orientação que reflete a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em inobservância da regra prevista no artigo 557, § 1° do CPC. 2. Não obstante o inadimplemento contratual não dar ensejo, em regra, à reparação de ordem extrapatrimonial, é possível, nos casos em que considerada injusta a recusa de cobertura por parte do plano de saúde, a condenação em pagamento de dano moral, quando a negativa agrava o contexto de aflição psicológica do segurado, ultrapassando os limites do mero desconforto ou aborrecimento, como ocorreu na hipótese. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 299.221/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/11/2013).

O E. TJMS também já decidiu, neste sentido:

"CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE QUE LIMITA SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. RECORRENTE COM SÍNDROME DE DOWN. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA NECESSIDADE DE SESSÕES REQUERIDAS. DANO MORAL COMPROVADO. APELO IMPROVIDO. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. Dano moral devidamente comprovado e mantido, posto que evidente a aplicação ao caso. Apelo improvido. (TJMS; APL 0811330-94.2013.8.12.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 07/07/2017; p. 107).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO. NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS RECURSAIS 1% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o menor possui um quadro severo de saúde, com sérios riscos de prejudicar o já combalido desenvolvimento cognitivo, caso não seja, submetido ao tratamento médico prescrito, é patente o dever da empresa recorrente em dispor da terapêutica indicada. (TJMS; APL Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 0802051-58.2016.8.12.0008; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 06/06/2017; p. 115).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

Desta forma, verificados os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), mostra-se cristalino o dever da requerida em indenizar o requerente, beneficiário do plano de saúde.

Como cediço, os danos morais devem ser arbitrados de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, entre as quais, a natureza da lesão, suas consequências, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, devendo, ainda, atender a dupla finalidade, punitiva/educativa e compensatória, porém sem causar o enriquecimento sem causa da parte.

No caso em apreço, a parte ré é instituição de grande porte, de forma que o montante deve ser arbitrado em valor que se mostra condizente com a função sancionatória do dano moral.

A importância fixada precisa mostrar-se razoável e proporcional ao poder econômico do ofensor, à sua culpabilidade e ao grau do dano, de forma a não se tornar inexpressivo e insignificante, escapando à função penalizadora e pedagógica da indenização, sem, também, se converter em fonte de enriquecimento sem causa da vítima, vindo esta a se beneficiar com o recebimento de importe superior ao que realmente lhe é devido.

Desta forma, levando as particularidades do caso em comento, as condições de cada parte, além da função punitiva/pedagógica da sanção, fixo o montante de **R$ 10.000,00 (dez mil reais),** a título de danos morais, sendo certo que tal quantia não irá interferir no patrimônio da requerida, sendo suficiente para reparar o requerente pelas ofensas sofridas, sem que isto lhe cause enriquecimento sem causa.

O valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado monetariamente pelo IGPM-FGV a partir de seu arbitramento, ou seja, a partir da data desta sentença, consoante enunciado da Súmula 362 do STJ (A correção monetária do valor da indenização o dano moral incide desde a data do arbitramento).

Sendo a relação de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Dispositivo

Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, **acolho o parecer ministerial de fls. 736/742, e julgo procedentes os pedidos formulados na inicial,** para o fim de:

- determinar que a ré custeie ao autor, Fernando Teruo Higa da Silva, o tratamento ABA (a ser realizado 5 (cinco) vezes na semana, em sessões com duração de uma hora cada, na Clínica Espasso Programa Comportamental) e do tratamento de Terapia Ocupacional (a ser realizado 3 (três) vezes por semana, em sessões com duração de 40 minutos cada, a serem realizadas pelas profissionais Érica Sinzato Grabalos CREFITO 12/6435/TO e Camila Balbuena G. De Almeida CREFITO 13-6719/TO), durante o período em que for necessário para a conclusão do tratamento, conforme laudo médico de f. 123/124 e 125/130, **restando ratificada a tutela de urgência deferida nos autos.**

- condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor da indenização deverá ser atualizado monetariamente pelo IGPM-FGV a partir de seu arbitramento, ou seja, a partir da data desta sentença. Já os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devem incidir a partir da data da citação.

Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

da condenação.

No mais, diante da conclusão da prova pericial, autorizo, independente do decurso do prazo recursal, a expedição de alvará em favor do expert, referente aos honorários periciais depositados nos autos, conforme dados bancários de f. 708.

Movimentos realizados
* Lançamentos com pagamento confirmado pela instituição financeira.

Data	Cód. Mov.	Cód. Alvará	Depositante/Beneficiário/Usuário	Complemento	TP	D/C	Valor R$
02/07/2018	2202627		Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, telefone: 6721072000 CPF/CNPJ: 03.315.918/0001-18	Depósito de honorários periciais.		C	4.770,00

Saldo da subconta em 23/06/2022 **

Total de Crédito:	4.770,00
Total de Correção:	29,08
Total de Juros:	729,62
Total de Débito:	0,00
Total de Valores Penhorados***:	0,00
Total de Valores Reservados (Débito) :	0,00
Total de Valores Reservados (Crédito) :	0,00

Saldo: **5.528,70**

** Movimentos de crédito pendentes e valores reservados de crédito não são incluídos no cálculo do saldo da Subconta.
*** Corresponde ao valor total de penhoras atualizados até a data informada.

Certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Grande-MS, *data da assinatura digital*.

Vania de Paula Arantes
Juiz(a) de Direito

Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 24/06/2022 às 08:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804991-80.2017.8.12.0001 e código r74Q5XFf.